

N. R.G. 1350/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati

dott. Giovanni Picciau

Presidente Rel.

dott. ssa Benedetta Pattumelli

Consigliere

dott.ssa Fiorella Perna

Consigliere Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di rinvio in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 28378/2023 , con ricorso proposto

DA

Parte_1 *C.F._1* con il patrocinio dell'avv. CIRILLO
ERNESTO MARIA (*C.F._2* e dell'avv. CIRILLO FRANCESCO
(*C.F._3* ; elettivamente domiciliato in VIA PODGORA 4 MILANO
presso lo studio dell'avv. ROSIELLO ANNALISA *C.F._4*

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

CONTRO

Controparte_1 *P.IVA_1* con il patrocinio dell'avv. CHIELLO ANGELO
GIUSEPPE *C.F._5* dell'avv. SIBANI FRANCESCO MARIA

(C.F._6 , dell'avv. POZZOLI CESARE (C.F._7) ,
elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIALE PREMUDA 27 20129
MILANO; elettivamente domiciliato

RESISTENTE IN RIASSUNZIONE

CONCLUSIONI

Per Parte ricorrente in riassunzione

“Tutto quanto sopra premesso, il sig. Parte_1 come in atti rapp.to, dom.to e difeso, nuova-mente richiamate anche tutte le difese ed istanze, anche istruttorie, di cui ai precedenti gradi di giudizio, senza quiescenza alcuna, insiste per il rigetto del reclamo proposto e, pertanto, affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, Voglia confermare l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, che di seguito si riportano:

I) dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato, perché il licenzia-mento è ritorsivo e/o discriminatorio, e per l'effetto ordinare alla Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e nelle mansioni ivi espletate e condannarla alla corresponsione del risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.350,73 come da buste paga versate in atti) dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra, oltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali;

II) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del licenziamento intimato al sig. Parte_1 per violazione dell'art. 2119 c.c. nonché dell'art. 48 lettera B del CCNL di categoria (e in ogni caso anche dell'art. 3 della L. 604/66), stante la manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, e per l'effetto, condannare la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 18 comma 7 Statuto dei Lavoratori, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.350,73 come da buste paga versate in atti) dal giorno del licenziamento sino a quello

dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali, ovvero alla diversa somma che riterrà l'On.le Giudicante;

III) In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare, l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al sig. Parte_1 e, per l'effetto, condannare Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere un'indennità risarcitoria sino a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.350,73 così come risultante dalle buste paga allegate) nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali, ovvero alla diversa somma che riterrà l'On.le Giudicante;

IV) Munire il provvedimento di clausola esecutiva;

V) Condannare la datrice al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, spese di contributo unificato, come per legge."

Si rinnovano altresì le istanze istruttorie formulate nelle precedenti fasi di merito e, da ultimo, così formulate nella memoria di costituzione in sede di reclamo:

"In via istruttoria:

Nell'ipotesi di impugnazione, senza alcuna inversione dell'onere della prova, si reiterano le istanze istruttorie già formulate e, comunque, si richiede di ammettere il comparente a provare per testimoni le circostanze di fatto contenute nei capi da 1 a 163 della premessa del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, iscritto al n.r.g. 5405/2018 del Tribunale di Milano, come anche riportate nelle presenti memorie al capo B) che qui abbinassi per ripetute e trascritte, con l'anteposizione della locuzione "Vero è che", ed indicando come testimoni i sigg.ri:

Testimone_1 via Teramo, 28 Milano; CP_2 via G.Galilei 19, Corsico (Milano); Controparte_3, via Monteverdi 9, Trezzano sul Naviglio (Milano); Testimone_2 via Diaz 21, Corsico (Milano); ad eccezione del capo 4) su cui si indica la sig.ra Parte_2 presso CGIL Milano.

Nonché ammettere il comparente a provare per testimoni le circostanze di fatto contenute nei capi da 1 a 242 delle memorie rese nel successivo giudizio di

opposizione r.g.n. 976/2019, come anche riportate nelle presenti memorie al capo E), che qui abbiansi per ripetute e trascritte, con l'anteposizione della locuzione "Vero è che", ed indicando come testimoni i sigg.ri: Testimone_1 via Teramo, 28 Milano; CP_2 via G.Galilei 19, Corsico (Milano); Controparte_3, via Monteverdi 9, Trezzano sul Naviglio (Milano); Testimone_2 via Diaz 21, Corsico (Milano); Ad eccezione dei capi 75 e 76 su cui si indica a teste il sig. Testimone_3, e dei capi 67 e 69 su cui si indicano a testi anche i sigg.ri Tes_4, Tes_5, Controparte_2, Dotti Tes_6 Testimone_7, e del capo 20) su cui si indica a teste a sig.ra Parte_2 presso CGIL Milano

Nonché si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capi eventualmente articolati da contro-parte e con i medesimi testi da questa indicati nonché con i propri testi e sui propri capi.

Ancora si richiede in via istruttoria, sempre senza inversione dell'onere probatorio:

- Disporsi l'ispezione giudiziale dei luoghi di lavoro;
- Ordinare all'azienda l'esibizione ed il deposito di tutti i documenti fondanti i supposti rilievi ed accertamenti relativi al procedimento disciplinare per cui è causa, nonché di ogni altro documento relativo al rapporto di lavoro de quo, ed alla attività produttiva del convenuto nel periodo per cui è causa.
- Ordinare alla Controparte_1 l'esibizione ed il deposito dei tabulati della sim aziendale 335 7689868 per le giornate lavorative di cui ai fatti contestati anche in ordine alle telefonate effettuate tramite i server aziendali;
- Ordinare alla Controparte_1 l'esibizione ed il deposito per le giornate lavorative di cui ai fatti contestati dei report degli accessi, utilizzi, e lavorazioni e risultanze di ogni genere del sistema WFM e di tutti i sistemi ed applicativi aziendali utilizzati dal lavoratore, nonché dello smartphone in dotazione con numerazione 335 7689868, anche in ordine alle telefonate effettuate attraverso i server aziendali, ed anche degli applicativi:
- nFAS- CLICK MOBILE:
<https://nwfmmobile.telecomitalia.it/ClickMobileWEB/Default.aspx?Culture=it>
IT
- OA FORMS: <https://oaforms.telecomitalia.it/#/login>

- APPONE: <https://one.tim.it/one/One>
- ATTIVATORE: <https://attivatore.telecomitalia.it/>
- CP_4 <https://helpme.tim.it/#/login>
- iSOFIA: <http://10.48.9.239/iSofia/>
- GEM: <https://nwfmextsvc.telecomitalia.it/UM/gemmobile/Login.jsp>
- NAVWEB: <https://navwebevo.tim.it/>
- SIGENT: <https://10.10.211.50/sigent/asp/general/login.asp>
- iAM: <https://iam.telecomitalia.it/uia/iam/HomeAction.action>
- RETROCARTELLINO:
http://10.19.36.197/retrocartellino_ant/formretrocartellinounificato.asp
- FOLLOW ME: <https://followme.telecomitalia.it/Security/Login.fm?>
- Si richiede che venga ordinato alla Controparte_1 la produzione degli eventuali contratti stipulati o lettere d'incarico a personale esterno per lo svolgimento di controlli occulti in merito alla vicenda in esame.
- Si chiede ordinarsi alla Controparte_1 l'esibizione ed il deposito del cedolino del mese di novembre 2017 non consegnato al lavoratore".

- Con vittoria di spese competenze e onorari delle fasi di merito, della fase di Cassazione e della presente fase di riassunzione, oltre accessori di legge ed attribuzione agli scriventi avvocati antistatari.

Per Parte resistente in riassunzione

si chiede che codesta Ill.ma Corte di Appello di Milano voglia rigettare il ricorso in riassunzione avversario e le domande tutte proposte dal sig. Parte_1 .

Con vittoria di spese ed onorari.

Previo rigetto delle avversarie istanze istruttorie, in quanto inammissibili.

Previa, solo occorrendo, ammissione della prova per testimoni sulle circostanze capitolate nella memoria difensiva di primo grado al par. n. 2, lett. E, nn. da 1 a 48 e sottonumerazioni tutte, tutti da intendersi preceduti dall'espressione "Vero che", con i testimoni ivi indicati, che si indicano anche a prova contraria sui capitoli avversari in caso di loro (denegata, in quanto valutativi e generici) loro ammissione in calce.

Fatto e diritto

Parte_1 ha riassunto, in seguito alla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n. 28378/2023, il procedimento dallo stesso promosso in primo grado ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 nei confronti di *Controparte_1*.

L'oggetto della controversia e lo svolgimento delle precedenti fasi del procedimento sono così riassunti nella sentenza di rinvio della Corte di Cassazione:

"1.- Parte_1 era stato dipendente di Controparte_1 fino al 29/11/2017, quando gli era stato intimato il licenziamento per ragioni disciplinari oggetto della previa contestazione del 22/11/2017.

Il dipendente impugnava il licenziamento, deducendone la nullità per ritorsività del motivo, ovvero per il suo carattere discriminatorio rispetto alla sanzione conservativa applicata al collega CP_5 per vicenda disciplinare coeva e identica; in subordine l'illegittimità per manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso ovvero perché il fatto rientrava fra le condotte punibili con sanzione conservativa; in ulteriore subordine l'illegittimità per sproporzione tra infrazione e sanzione, con conseguente tutela indennitario-risarcitoria.

2. Costitutosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano, a conclusione della fase sommaria, accoglieva la domanda principale e ordinava la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro.

L'opposizione proposta da Controparte_1 era rigettata ed il Tribunale condannava altresì la società a risarcire al ricorrente il danno liquidato in misura pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegrazione sulla base della retribuzione mensile di euro 2.350,73.

3. Proposto reclamo dalla società, la Corte d'Appello accoglieva il gravame, respingeva tutte le domande dell'ex dipendente e lo condannava a restituire quanto in ipotesi percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.

Per quanto rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

*a) in fatto va premesso che il **Parte_1**, nel periodo in esame (da settembre a novembre 2017), era inquadrato nel V livello ccnl telefonia, con mansioni di tecnico "on field" impianti e servizi, aveva come base la centrale **CP_1** in Milano Via dei Ciclamini, operando nella zona di Milano sud; quale tecnico "on field", egli non faceva riferimento ad una specifica sede di lavoro, ma partiva dal proprio domicilio e dalla centrale di ricovero dell'automezzo sociale e poi iniziava l'attività presso il cliente o sul primo impianto sul quale era chiamato ad operare;*

b) la contestazione disciplinare ha ad oggetto la falsa attestazione di tempi e modi di esecuzione delle attività lavorative a lui assegnate, lo svolgimento di un complessivo orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente dovuto senza alcuna riduzione corrispondente della retribuzione, l'essersi dedicato durante l'orario di lavoro ad incombenze legate alla sfera personale di interessi e comunque estranee all'attività lavorativa; nella contestazione sono analiticamente riportati i giorni e gli episodi in cui tali condotte sono state tenute;

c) i motivi di impugnazione, da esaminare congiuntamente, sono volti a contrastare la tesi – accolta dal Tribunale – della sussistenza di plurimi e concordanti elementi presuntivi idonei a provare la ritorsività del licenziamento, quali:

- la volontà di punire il lavoratore che aveva avviato un terzo contenzioso nei confronti della società;

- l'abusivo ricorso a controlli investigativi disposti nei suoi confronti, con conseguente inutilizzabilità dei fatti emersi al loro esito;

*- il differente e ingiustificato trattamento subito dal **Parte_1** rispetto al collega **CP_5**, punito con sanzione conservativa, nonostante l'identità delle posizioni e delle contestazioni disciplinari;*

*- l'intimazione del licenziamento quando il Tribunale non si era ancora pronunciato sulla causa relativa alla c.d. franchigia, mentre la sanzione conservativa dell'**CP_5** era stata comminata due giorni dopo la sentenza con cui il Tribunale*

aveva rigettato la domanda dei lavoratori relativa alla c.d. franchigia, ossia quando era ormai certo il risultato negativo per i lavoratori e favorevole alla società;

d) in particolare l'abusività del ricorso al controllo investigativo è stata desunta dal Tribunale dalla concomitanza fra l'inizio del pedinamento (28/09/2017) e la prima udienza di discussione (29/09/2017) del ricorso promosso per la c.d. franchigia e comunque dal breve lasso di tempo intercorso fra la notifica del ricorso e la scelta di conferire l'incarico all'agenzia investigativa;

e) ad avviso del Tribunale, la scelta della società è da qualificare come reazione ingiusta ed arbitraria ad un comportamento legittimo del lavoratore considerato sgradito perché "disturbatore";

f) questa tesi non può essere condivisa, per varie ragioni:

*- il ricorso del giugno 2017 era stato proposto dal **Parte_1** insieme ad **CP_5** e ad altri quattro lavoratori ed ineriva ad un contenzioso seriale, già avviato sia in Milano, sia presso altri fori sin dal 2015, da circa una quarantina di dipendenti; l'esito di questo contenzioso era stato complessivamente sfavorevole ai dipendenti, perché solo due giudizi (non dinanzi al Tribunale di Milano) avevano avuto esito favorevole per i ricorrenti; dunque l'azione promossa dal **Parte_1** non presentava un rischio di particolare gravità;*

*- i controlli investigativi sono stati avviati solo nei confronti di **Parte_1** e **CP_5**, il che indebolisce la tesi dell'intento punitivo, visto che i dipendenti che avevano proposto quel ricorso per la c.d. franchigia erano in tutto sei;*

*- il riferimento ai precedenti ricorsi promossi dal **Parte_1** non è convincente, atteso che quello del 2010 per il riconoscimento del 5[^] livello era terminato con una conciliazione, sicché non è plausibile una reazione a distanza di sette anni; quello del 2016 era stato un ricorso amministrativo tramite Corecom per una questione tariffaria del valore di circa 500 euro conclusosi anch'esso con una conciliazione, sicché non è verosimile che abbia ingenerato nella società un risentimento così forte da spingerla a licenziare il dipendente circa tredici mesi dopo;*

- il contrasto con l'ufficio del personale alla fine del 2016 in tema di godimento di permessi del 2014 si è risolto senza alcuna vertenza e quindi rientrava nelle ordinarie dinamiche di gestione del rapporto di lavoro;

- i controlli investigativi sono stati avviati anche nei confronti di CP_5 , il quale non risulta avesse avuto precedenti contenziosi con la società;

- la scelta del momento in cui iniziare il pedinamento è stata autonomamente assunta dalla società incaricata, estranea al contenzioso, sicché è del tutto irrilevante il fatto che quel pedinamento sia iniziato proprio il giorno prima della prima udienza del ricorso relativo alla c.d. franchigia;

- è peraltro significativo il fatto che la società abbia attivato il controllo investigativo non immediatamente dopo la ricezione della notifica del ricorso, bensì tre mesi dopo;

g) la società ha motivato la richiesta di controlli investigativi sospettando che fossero distratte ore di lavoro per attività non inerenti ovvero in concorrenza o comunque incompatibili con gli obiettivi aziendali, in quanto il Parte_1 era solito operare all'esterno sempre senza divisa e senza esporre il badge, pur essendo ciò invece richiesto dalla società; tale giustificazione, esposta anche nel mandato investigativo, è plausibile;

h) infatti, che i controlli investigativi siano stati avviati per identica ragione anche nei confronti di CP_5 , il quale a sua volta operava senza divisa, ma non pure nei confronti del collega CP_2 che invece indossava sempre la divisa, e il fatto che pure il CP_2 con CP_5 e Parte_1 , avesse promosso la causa sulla c.d. franchigia sono tutti elementi che inducono a ritenere ragionevole il motivo addotto dalla società per iniziare i controlli investigativi e tolgono ulteriormente rilevanza al contenzioso sulla c.d. franchigia quale possibile elemento presuntivo di ritorsività;

i) sulla legittimità delle indagini investigative si richiama il principio di diritto affermato da Cass. n. 4670/2019;

j) quanto all'asserito ingiustificato peggior trattamento sanzionatorio del Parte_1 rispetto a quello riservato ad CP_5 , nonostante l'asserita identità delle contestazioni disciplinari, va considerato che, sul piano quantitativo, le false attestazioni del Parte_1 sono state 17, mentre quelle di CP_5 erano state 9; inoltre, nel corso del procedimento disciplinare CP_5 , che lavorava in parte da remoto, a differenza del Parte_1 che operava solo all'esterno, aveva fornito una dettagliata ricostruzione delle modalità di svolgimento dei suoi incarichi, indicando sia il nominativo dei colleghi in grado di confermare le sue affermazioni, sia idonea documentazione, tanto da ridimensionare la gravità degli addebiti a lui mossi; invece il Parte_1 non ha fornito alcuna giustificazione delle condotte, ma si era limitato

a riconoscere che i tempi di gestione non erano coerenti con quanto da lui dichiarato ed aveva affermato solo di aver “allungato” le tempistiche, cosa invece non esatta, in quanto gli addebiti comprendevano anche mancate esecuzioni di incarichi assegnati, rispetto ai quali il lavoratore nulla aveva replicato;

*k) quindi il comportamento del **Parte_1** è stato complessivamente più grave di quello del collega **CP_5** e tanto giustifica il diverso trattamento sanzionatorio;*

*l) quanto ai diversi tempi di adozione del provvedimento disciplinare, questa si giustifica per il fatto che la sanzione doveva essere adottata entro dieci giorni dalle giustificazioni e in entrambi i casi ciò è avvenuto entro due giorni da quello dell’incontro; il fatto che la sanzione per **CP_5** sia intervenuta dopo l’esito del ricorso è solo dovuto alle due diverse date di avvio dei due procedimenti disciplinari (22 novembre per il **Parte_1** ; 11 dicembre per **CP_5**), a sua volta dovute ai diversi momenti in cui erano terminate le rispettive investigazioni ed erano pervenute alla società le relazioni;*

m) dunque una volta ritenuti legittimi i controlli investigativi e quindi utilizzabili i loro esiti, dall’istruttoria svolta è emersa la fondatezza degli addebiti, come peraltro affermato per inciso anche dal Tribunale;

n) la nullità del licenziamento va esclusa qualora concorra un motivo lecito di recesso, mancando in tal caso il necessario carattere determinate del motivo illecito ex art. 1345 c.c., che potrà essere affermato solo nel caso in cui il motivo addotto a sostegno del licenziamento risulti solo formale ed apparente (Cass. n. 9468/2019);”

*o) le deposizioni testimoniali hanno confermato tutti gli addebiti, relativi alle WR (incarichi da svolgersi all’esterno), per i quali il **Parte_1** non è stato in grado di fornire dati concreti, coerenti e convincenti, preferendo richiamare solo imprecise esigenze tecniche;*

p) nessuna giustificazione il lavoratore inoltre ha dato in ordine alle diverse incombenze, di natura personale, svolte durante l’orario di lavoro;

*q) dunque il **Parte_1** , abusando dell’autonomia organizzativa propria della posizione ricoperta, attestava in maniera non veritiera l’inizio e/o il termine della prestazione giornaliera, facendo così risultare un numero di ore di gran lunga superiore a quelle effettivamente svolte;*

r) gli addebiti mossi, risultati tutti sussistenti, sono di gravità tale da far venir meno il rapporto fiduciario, anche in considerazione del fatto che trattandosi di un lavoratore la cui attività si svolgeva quasi esclusivamente all'esterno, da lui ci si attendeva un elevato livello di affidabilità, serietà e coscienziosità; era infatti lui che, compilando autonomamente le schede sul sistema informatico, riportava gli orari di presa in carico e di termine della [redacted] il rispetto delle tempistiche e l'attuazione o meno dell'intervento richiesto;

s) l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare è infondata, atteso che la lettera contiene un'analitica e completa esposizione dei fatti, con specificazione delle date, dei codici e del tipo di lavorazioni interessate, gli orari appuntati sul sistema informatico e quelli effettivamente rilevati dall'investigatore.

4.- Avverso tale sentenza [redacted] Parte_1 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi.

5.- [redacted] Controparte_1 ha resistito con controricorso.

6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità del procedimento per violazione dell'art. 83 d.l. n. 18/2020, nonché delle linee guida della Presidenza della Corte d'Appello di Milano, per avere la società depositato note scritte non limitate alle sole conclusioni, bensì vere e proprie note difensive non autorizzate, contenenti peraltro due documenti allegati, sui quali non è stato garantito il contraddittorio, come invece previsto dalle predette linee guida.

Assume che in alcune parti della sentenza la Corte d'Appello si sarebbe basata proprio su quelle note difensive non autorizzate e sui documenti così tardivamente depositati, come ad esempio a pag. 16, laddove si era riferita al provvedimento del Garante per la privacy n. 8 del 09/01/2020 e lo aveva ritenuto inapplicabile perché riguardante non il sistema "WFM" utilizzato all'epoca dei fatti, bensì il nuovo sistema "nWFM";

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti, a causa dell'omessa considerazione dell'inutilizzabilità e/o inammissibilità dei dati estratti dal sistema WFP determinata sia dal fatto che quel sistema rappresentava un

controllo a distanza, sia dalla mancata prova della necessaria informativa al lavoratore ex art. 4, co. 3, L. n. 300/1970;

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 4 L. n. 300/1970, 2119, 2014 e 2106 c.c., del d.lgs. n. 196/2003 vigente al tempo dei fatti, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato applicabile l'art. 4 L. n. 300/1970;

Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto storico determinate ai fini della decisione e oggetto di discussione fra le parti. In particolare addebita alla Corte territoriale l'omessa considerazione della mancata indicazione, nel mandato investigativo, dei nominativi degli investigatori delegati all'esecuzione delle indagini;

Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2119 c.c., 2, 3, 4, 8 e 18 L. n. 300/1970, 11 e 12 d.lgs. n. 196/2003, 8 del relativo allegato A.6, 2, 3, 13, 14 e 15 Cost. sul diritto alla riservatezza, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., come conseguenza dell'omesso esame oggetto del quarto motivo;

Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto storico determinante ai fini della decisione e oggetto di discussione fra le parti, ossia l'avvenuto conferimento del mandato investigativo da parte di un soggetto – tale sig. Persona_1 – privo dei relativi poteri;

Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1703 e 2119 c.c., 2, 3, 4, 8 e 18 L. n. 300/1970, 11 e 12 d.lgs. n. 196/2003 e del relativo allegato A.6, nonché degli artt. 2, 3, 13, 14 e 15 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

Con l'ottavo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto storico determinate ai fini della decisione e oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sull'eccepita mancanza, in capo a CP_6, delle prescritte licenze prefettizie ai sensi dell'art. 134 TULPS e del D.M. n. 269/2010;

Con il nono motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 134 TULPS e del D.M. n. 269/2010, nonché – nuovamente – degli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 196/2003, 2, 3, 13, 14, e 15 Cost., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto legittime le investigazioni pur in assenza delle necessarie licenze prefettizie;

Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2, 3, 4, 8 e 18 L. n. 300/1970, 45 ccnl telecomunicazioni, nonché degli 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto legittime le indagini investigative nonostante fossero attinenti all'adempimento della prestazione lavorativa;

Con l'undicesimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 47 e 48 ccnl telecomunicazioni, 2119 e 2106 c.c., 30 L. n. 183/2010, 18 L. n. 300/1970, per avere la Corte territoriale omissa di verificare se gli addebiti disciplinari potessero rientrare nell'ambito di una sanzione conservativa, come invece impone l'art. 30 L. n. 183 cit.;

Con il dodicesimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa" [applicazione] degli artt. 2119, 2106 c.c., 18 L. n. 300/1970, 2712 e 2719 c.c., 21 e 23 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), 155 [rectius 115] e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la sua decisione anche sugli "estratti della procedura aziendale, registrazione dei dati del badge", di cui egli aveva contestato l'idoneità rappresentativa dei fatti contestati, sia in relazione all'autenticità, sia in relazione al contenuto, sia in relazione alla riconducibilità di quei dati al lavoratore".

La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi del ricorso ritenendo invece fondati il quarto e il quinto motivo e assorbiti i restanti (6-12), così testualmente statuendo:

"I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Con riguardo al primo, l'eventuale violazione del contraddittorio relativo a quel profilo controverso – l'essere il sistema WFM destinato oppure no al controllo a

distanza della prestazione lavorativa – è irrilevante, poiché la Corte d'Appello ha motivato soprattutto sul fatto che era lo stesso tecnico ad inserire nel sistema informatico tempi e modalità di esecuzione della sua prestazione lavorativa (v. supra sub r). La condotta oggetto di contestazione disciplinare è consistita nell'aver inserito nel sistema informatico dati falsi, ossia non rispondenti al vero.

Ne deriva che quel sistema WFM nel presente giudizio rileva non come sistema del datore di lavoro per effettuare un controllo sulla prestazione lavorativa, ma come mezzo adoperato dal dipendente per fornire al datore di lavoro dati falsi.

L'ulteriore conseguenza è l'irrilevanza del provvedimento del garante datato 09/01/2020 e, dunque, l'evidente superfluità della motivazione della Corte territoriale sul punto (pur volendo prescindere dalla considerazione per cui l'inapplicabilità di quel provvedimento ratione temporis è desumibile dalla collocazione temporale - anno 2017 - delle condotte contestate in via disciplinare).

Quindi, nessun rilievo effettivo hanno avuto quelle note e quei documenti sul convincimento della Corte territoriale, sicché l'asserita violazione del contraddittorio è stata solo formale, ma non ha comportato alcun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del Parte_1, né ha avuto reale incidenza sulla decisione del gravame da parte dei giudici del reclamo.

Anche il secondo ed il terzo motivo sono infondati. Va premesso che il lavoratore non ha mai eccepito di non sapere adoperare il sistema WFM o di essere caduto in errore nel suo utilizzo o di non aver digitato quei dati tecnici (che non attengono alla dignità e alla riservatezza del dipendente), utilizzati dalla società nella contestazione disciplinare, ma si è limitato ad una difesa meramente formale, volta a negare di aver ricevuto le informazioni relative al sistema WFM invece necessarie ai sensi dell'art. 4, co. 3, L. n. 300/1970.

Ciò esclude che sussista una causa di inutilizzabilità di quei dati, forniti dallo stesso lavoratore, dal momento che essi rilevano non quale esito di un controllo a distanza della prestazione lavorativa, bensì come elementi da raffrontare con l'esito delle indagini investigative. A ben vedere, quegli elementi integrano proprio gran parte delle condotte disciplinarmente rilevanti, sicché non è pertinente il richiamo all'art. 4 L. n. 300/1970.

Quanto poi alle indagini investigative, va premesso che nel caso dei cc.dd. controlli difensivi, svolti a mezzo di impianti tecnologici, questa Corte ha escluso l'applicabilità

dell'art. 4 L. n. 300/1970 qualora siano «finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto» (Cass. 22/09/2021, n. 25732).

A tal riguardo si è precisato che «spetta al datore l'onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l'hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico "ex post", sia perché solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 st. lav., sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 l. n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento» (Cass. 26/06/2023, n. 18168).

Le medesime considerazioni consentono di escludere l'applicabilità anche degli artt. 2 e 3 L. n. 300/1970. Questa Corte ha già affermato che «Le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione» (Cass. 14/02/2011, n. 3590). Dunque «I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.» (Cass. ord. 11/06/2018, n. 15094).

Ciò è quanto ricorre nel caso di specie: come accertato dalla Corte territoriale, la condotta tenuta dal Parte_1 è stata connotata da frode idonea a conseguire

indebiti arricchimenti a danno della società datrice di lavoro. Dunque, si è trattato di comportamenti fraudolenti fonti di danno per la società datrice di lavoro.

Con ulteriore deduzione – sviluppata dal ricorrente nella sua memoria – il ricorrente sostiene che il sospetto che aveva giustificato l'avvio di indagini cc.dd. difensive era per eventuali atti di concorrenza compiuti dal dipendente, sicché – a suo dire – una volta che quelle indagini avevano dato esito negativo si sarebbero dovute arrestare o comunque non avrebbero potuto investire altri comportamenti del lavoratore, né tantomeno risolversi in controlli sulla prestazione lavorativa, pena l'inutilizzabilità dei dati raccolti.

Anche tale deduzione è infondata.

Il sospetto – oggettivamente sussistente e giustificato – consente l'avvio delle indagini investigative e la loro legittimità, ma non ne limita affatto l'oggetto. Certo questo non può sconfinare in controlli sulla prestazione lavorativa, che non possono essere affidati a terzi estranei all'organizzazione datoriale (art. 3 L. n. 300/1970). Ma nel caso in esame non si è verificato questo sconfinamento, atteso che i comportamenti scoperti a seguito delle predette indagini hanno avuto ad oggetto prestazioni rese in favore di terzi (non in concorrenza con CP_1) durante l'orario di lavoro o per scopi estranei all'attività di impresa datoriale. Quindi gli esiti di quelle indagini sono stati utilizzati dalla datrice di lavoro non per controllare la prestazione lavorativa (anche sotto il profilo della sua esattezza), bensì per accertare prima e dimostrare poi le falsità integranti "artifici e raggiri" tipici di un vero e proprio reato (truffa), posto in essere dal dipendente nel momento in cui trasmetteva i dati attraverso il sistema WFM. Inammissibile, infine, è il motivo nella parte in cui si denuncia la "violazione e falsa applicazione" di tutto il d.lgs. n. 196/2003, per evidente ed assoluta genericità (o aspecificità), non avendo il ricorrente indicato quale delle varie norme contenute nel predetto testo normativo sarebbe stata asseritamente violata dalla Corte territoriale. Come questa Corte ha precisato, «In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla

Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa» (Cass. sez. un. 28/10/2020, n. 23745).

2.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto storico determinate ai fini della decisione e oggetto di discussione fra le parti. In particolare, addebita alla Corte territoriale l'omessa considerazione della mancata indicazione, nel mandato investigativo, dei nominativi degli investigatori delegati all'esecuzione delle indagini.

Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2119 c.c., 2, 3, 4, 8 e 18 L. n. 300/1970, 11 e 12 d.lgs. n. 196/2003, 8 del relativo allegato A.6, 2, 3, 13, 14 e 15 Cost. sul diritto alla riservatezza, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., come conseguenza dell'omesso esame oggetto del quarto motivo.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

L'indicazione del nominativo dei soggetti che in concreto hanno eseguito le indagini, se non riconducibili alla società di investigazione che ha ricevuto l'incarico, è un requisito di validità e di liceità di tali indagini e di utilizzabilità del relativo esito, pur se demandate a soggetto all'uopo dotato delle necessarie autorizzazioni amministrative (nella specie Parte_4, per la quale peraltro il ricorrente ha contestato nei vari gradi di giudizio il possesso delle predette autorizzazioni, contestazioni poi tradotte nell'ottavo motivo).

Nel caso di specie dagli atti del giudizio di primo grado, riportati anche dal ricorrente, risulta che l'autore materiale del pedinamento (tale Controparte_7 [...]) dichiarò in sede di deposizione testimoniale di lavorare per [...] CP_8

Questo fatto è rilevante. E' vero che – come ammesso pure dal ricorrente – in sede di opposizione Controparte_1 produsse la lettera di incarico a Parte_4, in cui vi era l'espressa clausola (1.4.) che autorizzava quest'ultima società ad "avvalersi della collaborazione operativa di agenti della Società del Gruppo Ponzi Investigazioni srl ... mantenendo sempre la governance, il coordinamento operativo e l'attività di reporting finale" (v. ricorso per cassazione, p. 30).

Tuttavia, è altresì vero che, come lamenta il ricorrente, nel medesimo mandato investigativo all'art. 2 era previsto che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, qualora Parte_4 si fosse avvalsa di altri investigatori privati esterni alla propria struttura, avrebbe dovuto indicare i relativi nominativi in calce all'atto di incarico.

Invece, l'indicazione dei nominativi degli investigatori CP_7 e Per_2 collaboratori di Controparte_8 è mancata sia ab origine, sia ex post in calce al mandato ricevuto.

Tale mancanza inficia il mandato e comporta, di conseguenza, l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, dei dati raccolti da soggetti non legittimati a farlo. In tal senso è l'autorizzazione n. 6/2016 del Garante per la protezione dei dati personali, registro dei provvedimenti n. 528 del 15/12/2016, invocata dal ricorrente a pag. 43 della memoria nella fase di opposizione del giudizio di primo grado (v. ricorso per cassazione, pp. 30-31), in cui è previsto che "l'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico".

Nello stesso senso, ancora più in generale, è l'art. 8, co. 4, del provvedimento del garante n. 60 del 06/11/2008, allegato A.6 al d.lgs. n. 196/2003 – REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI EFFETTUATI PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE O PER FARE VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA (indicato e richiamato nello stesso art. 2 dell'incarico investigativo conferito a Parte_4 come riportato dal ricorrente: v. ricorso per cassazione, p. 30). In particolare, l'art. 8 cit. dispone:

"1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.

2. L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice.

3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale

l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante.

5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.

6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova".

Sulla valenza "normativa" delle prescrizioni contenute nei codici deontologici non può esservi dubbio. Essa è conferita dall'art. 12 d.lgs. n. 196/2003, che ne prevede anche un regime di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale (co. 2) e prescrive il relativo rispetto come "condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici" (co. 3). La qualificazione giuridica in termini di "illiceità" del trattamento qualora non rispettoso delle regole conformative dettate dai predetti codici, infatti, implica necessariamente la natura normativa (e inderogabile) della fonte violata.

La medesima forza normativa è ora riconosciuta ai predetti codici dall'art. 2-quater, co. 4, d.lgs. n. 196/2003 introdotto dal d.lgs. n. 101/2018 contenente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Dall'art. 12 d.lgs. n. 196/2003 – e oggi dall'art. 2 quater, co. 4 del medesimo decreto legislativo – si desume allora la natura normativa di tali codici, che vanno qualificati esattamente come “fonti normative integrative”. In tal senso si è già pronunciata questa Corte (Cass. 06/06/2014, n. 12834 in materia di conflitto tra riservatezza, attività giornalistica e diritto di cronaca “fotografica”).

Ne consegue che per tali codici vale il principio iura novit curia, sicché il giudice deve individuarli e farne applicazione a prescindere dalla loro invocazione dalla parte interessata. Ulteriore conseguenza è la loro invocabilità con ricorso per cassazione sub specie di “violazione o falsa applicazione di norma di diritto”, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

Sul piano delle conseguenze, la violazione di tali codici determina l'inutilizzabilità dei dati in tal modo raccolti. In tal senso dispone l'art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, vigente ratione temporis: “I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati”.

Tale norma è stata poi abrogata dal d.lgs. 10/08/2018, n. 101, che, con l'art. 2, l'ha sostituita con l'art. 2-decies contenente identica formulazione, con l'unica aggiunta della salvezza di quanto previsto dall'art. 160 bis d.lgs. n. 196 cit. (quest'ultimo pure introdotto nell'anno 2018)

A sua volta l'art. 160 bis dispone: “La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali”.

Orbene, a differenza del codice di procedura penale (ad esempio artt. 33 nonies, 62, 64, 141 bis, 191, 195, 203, co. 1 bis, 357, co. 3 ter etc.), quello di rito civile non prevede espressamente la categoria giuridica della “inutilizzabilità” della prova o di un atto processuale. Da questa lacuna potrebbe dedursi che nel processo civile la predetta clausola (contenuta nell'art. 2-decies d.lgs. n. 196 cit.) implicherebbe la salvezza del potere discrezionale del giudice di decidere caso per caso se il dato (rectius la sua valenza rappresentativa del fatto da provare) sia utilizzabile oppure no ai fini della decisione e, ab imis, se il relativo mezzo di prova chiesto dalla parte sia ammissibile oppure no, prescindendo del tutto dalla illiceità della formazione del dato e del suo trattamento.

D'altro canto potrebbe obiettarsi che, sebbene non espressamente prevista, la categoria della "inutilizzabilità" della prova o dell'atto processuale sarebbe comunque evincibile dal complessivo sistema processuale civile, in quanto desumibile sia dal regime delle preclusioni istruttorie (art. 183 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022), sia più in generale da quello della nullità degli atti processuali ex art. 157 c.p.c. (secondo cui l'atto nullo non può produrre alcun effetto e, pertanto, non può essere "utilizzato": Cass. n. 23352/2022, secondo cui nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso, atteso il tassativo disposto dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che implica necessariamente "l'inutilizzabilità" di atti diversi da quelli suindicati).

A conforto di questa seconda ricostruzione sarebbe possibile invocare la giurisprudenza civile di questa Corte, che ricorre sovente alla categoria dell'inutilizzabilità della prova (Cass. ord. n. 22915/2023, secondo cui l'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non comporta "l'inutilizzabilità" a fini probatori della relativa produzione documentale; Cass. ord. n. 2397/2022, secondo cui il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, ove non sia raggiunta la prova della sua provenienza dalla parte che l'ha disconosciuta, determina "l'inutilizzabilità" del documento ai fini della decisione, anche soltanto in termini di fonte di indizi).

Tuttavia, in questa sede non occorre esaminare funditus la questione, poiché la portata della novella del 2018 non rileva ratione temporis nel caso in esame.

Pertanto, trova applicazione l'art. 11 d.lgs. n. 196 cit. nella sua formulazione originaria ed assoluta, ossia senza limiti né clausole di salvezza, sicché deve ritenersi che il legislatore abbia inteso imporre un'accezione rilevante sia in sede processuale, sia in sede extraprocessuale.

La tesi, pur sostenuta da parte della dottrina, secondo cui la disciplina del trattamento dei dati sarebbe (anche prima della novella del 2018) "irrilevante" nell'ambito del processo civile, che resterebbe soggetto alle regole sue proprie, non può essere condivisa. La sua conseguenza, infatti, sarebbe l'utilizzabilità di quei dati sia dalle parti per adempiere i propri oneri probatori, sia dal giudice per la sua decisione. Ma in tal modo si finirebbe per porre l'ordinamento in contraddizione con sé stesso, poiché da un lato qualificherebbe quel trattamento dei dati come "illecito", dall'altro permetterebbe la produzione di quei dati in un

giudizio civile, ossia una diffusione altrimenti vietata, ed inoltre consentirebbe alla parte di trarre in tal modo vantaggio da un'attività illecita (con pericolosi effetti incentivanti di tale illecito), ciò che è contrario ai principi generali, fra i quali quello del "giusto processo" ex art. 111 Cost.

Pertanto, l'art 11 d.lgs. n. 196 cit., nella sua formulazione originaria, va inteso nel senso assoluto di cui si è detto.

Ne consegue che sul piano processuale tale norma preclude non solo alle parti di avvalersi dei predetti dati come mezzo di prova, ma pure al giudice (nella controversia diversa da quella avente ad oggetto il provvedimento del Garante relativo al trattamento dei dati personali) di fondare il proprio convincimento su fatti dimostrati dal dato acquisito in modo non rispettoso delle regole dettate dal legislatore e dai codici deontologici.

D'altronde, questa assolutezza si spiega in chiave "funzionale": la ratio della norma è quella di scoraggiare la ricerca, l'acquisizione e più in generale il trattamento "abusivi" di dati personali e per realizzare questa funzione il rimedio previsto dal legislatore è quello di impedirne la realizzazione dello scopo (id est la successiva utilizzazione di quei dati).

Nel caso in esame, non essendo stati indicati neppure successivamente (in calce alla lettera di incarico) i nominativi degli investigatori "esterni" di cui si è avvalsa
Parte_4 *– come accertato in fatto dalla Corte territoriale –, viene meno l'utilizzabilità (in senso assoluto) della relazione investigativa e dei dati da essa evincibili.*

Ne deriva un'ulteriore conseguenza: viene meno la possibilità del raffronto di quei dati con quelli dichiarati dal *Parte_1* *nel sistema WFM e, quindi, la possibilità di verificarne la veridicità e, in ultima analisi, di contestarne la falsità mediante il procedimento disciplinare. In tal senso l'inutilizzabilità, proprio perché "assoluta" (ratione temporis), opera già in fase extraprocessuale e, quindi, sul piano sostanziale nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato come limite al potere datoriale.*

L'eccezione della controricorrente di inammissibilità di tale questione, perché non tempestivamente sollevata dal *Parte_1* *nel giudizio di opposizione, è infondata.*

Come precisato sul punto dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, pp. 30-31) egli in sede di memoria difensiva rispetto all'opposizione proposta dalla società, a pag. 43 aveva puntualmente dedotto la questione. Tale atto processuale è stato ritualmente da lui prodotto (all. E al ricorso per cassazione).

Il giudice di rinvio dovrà pertanto trarne le relative conseguenze, anche sul piano degli oneri probatori, alla luce del seguente principi di diritto:

«1) i codici deontologici di cui al d.lgs. n. 196/2003 hanno natura normativa e pertanto possono e devono essere individuati ed applicati anche d'ufficio dal giudice (iura novit curia);

2) la violazione dei predetti codici deontologici può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. e determina l'inutilizzabilità dei dati così raccolti;

3) l'inutilizzabilità dei dati raccolti in violazione dei codici deontologici di cui al d.lgs. n. 196/2003, nel periodo anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 101/2018, è da intendersi come "assoluta", quindi rilevante in sede sia processuale che extraprocessuale;

4) tale inutilizzabilità "assoluta" determina l'impossibilità sia per il datore di lavoro di porli a fondamento di una contestazione disciplinare e poi di produrli in giudizio come mezzo di prova, sia per il giudice di merito di porli a fondamento della sua decisione".

3- Restano pertanto assorbiti: il sesto; il settimo; l'ottavo; il nono; il decimo; l'undicesimo e il dodicesimo motivo".

Parte_1 con atto depositato in data 28/12/23 ha riassunto la causa, chiedendo alla Corte di applicare il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione.

Con memoria depositata in data 01/03/24 si è costituita in giudizio *CP_1* insistendo per il rigetto del ricorso in riassunzione avversario e di tutte le domande proposte da *Parte_1*.

All'udienza del 27 Giugno 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione ex art. 1, comma 60 e ss. l. 92/2012.

Va innanzitutto ricordato che , in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto , la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto ; in altri termini questa Corte , in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata , attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell’ambito della sua enunciazione .

Ciò premesso , va osservato che appaiono superate, come correttamente osserva parte resistente in riassunzione alle pagine 57 e 58 della memoria , alla luce del rigetto dei primi tre motivi del ricorso di Cassazione, tutte le questioni , pur se riproposte in questo grado di rinvio , oggetto di quei primi tre motivi.

Appaiono inoltre superate , così come pure osserva correttamente parte resistente in riassunzione (v. pagg. 53 e ss. della memoria) , le questioni inerenti la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento nonché quella relativa alla assenza di specificità della contestazione .

Si tratta di questioni già disattese dalla Corte di Appello con la sentenza n. 458 /2020 con statuizioni non oggetto di gravame nel ricorso per cassazione e che debbono quindi ritenersi coperte dal passaggio in giudicato.

Alla luce poi dei richiamati principi cui deve attenersi il giudice del rinvio, ritiene il Collegio che nella fattispecie debba essere dichiarata la illegittimità dell’impugnato licenziamento con l’applicazione della tutela di cui all’art.18, comma 4 della l. 300/1970.

In tal senso va evidenziato che nella sentenza di rinvio la Corte di Cassazione ha precisato in conclusione :

“ Il giudice di rinvio dovrà pertanto trarne le relative conseguenze, anche sul piano degli oneri probatori, alla luce del seguente principi di diritto:

«1) i codici deontologici di cui al d.lgs. n 196/2003 hanno natura normativa e pertanto possono e devono essere individuati ed applicati anche d’ufficio dal giudice (iura novit curia);

2) la violazione dei predetti codici deontologici può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. e determina l'inutilizzabilità dei dati così raccolti;

3) l'inutilizzabilità dei dati raccolti in violazione dei codici deontologici di cui al d.lgs. n. 196/2003, nel periodo anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 101/2018, è da intendersi come "assoluta", quindi rilevante in sede sia processuale che extraprocessuale;

4) tale inutilizzabilità "assoluta" determina l'impossibilità sia per il datore di lavoro di porli a fondamento di una contestazione disciplinare e poi di produrli in giudizio come mezzo di prova, sia per il giudice di merito di porli a fondamento della sua decisione". "

Nella articolata e diffusa motivazione della sentenza di rinvio (che si è in precedenza ritenuto opportuno riportare integralmente) la Corte di Cassazione ha precisato :

" Nel caso in esame, non essendo stati indicati neppure successivamente (in calce alla lettera di incarico) i nominativi degli investigatori "esterni" di cui si è avvalsa Parte_4 – come accertato in fatto dalla Corte territoriale –, viene meno l'utilizzabilità (in senso assoluto) della relazione investigativa e dei dati da essa evincibili.

Ne deriva un'ulteriore conseguenza: viene meno la possibilità del raffronto di quei dati con quelli dichiarati dal Parte_1 nel sistema WFM e, quindi, la possibilità di verificarne la veridicità e, in ultima analisi, di contestarne la falsità mediante il procedimento disciplinare. In tal senso l'inutilizzabilità, proprio perché "assoluta" (ratione temporis), opera già in fase extraprocessuale e, quindi, sul piano sostanziale nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato come limite al potere datoriale. "

La Corte di Cassazione , quindi , afferma in modo perentorio che , attesa l'inutilizzabilità in senso assoluto dei dati evincibili dalla relazione investigativa viene meno la possibilità di raffrontarli con quelli dichiarati da Parte_1 nel sistema WMF e quindi la possibilità di verificare la veridicità di questi ultimi e , quale limite al potere datoriale sul piano sostanziale nell'ambito del rapporto di

lavoro , di contestare la falsità dei dati dichiarati mediante procedimento disciplinare .

L'inutilizzabilità assoluta di dati investigativi determina l'impossibilità di porli a fondamento di una contestazione disciplinare e poi di produrli in giudizio come mezzo di prova.

Nella fattispecie non appare allora seriamente contestabile , ad avviso del Collegio, che le risultanze dei dati della relazione investigativa ritenuti inutilizzabili dalla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione costituissero il fondamento della contestazione disciplinata mossa a *Parte_1* per ravvisare e contestare la non veridicità dei dati dichiarati dal lavoratore nel sistema WMF nei giorni e negli orari specificati nella contestazione.

In tale contesto, ad avviso del Collegio , già sul piano della mera contestazione , viene meno la possibilità che la stessa , depurata del raffronto con i dati della indagine investigativa , possa essere intesa (contrariamente a quanto pare alludere *CP_1* nella memoria di costituzione in grado di rinvio) come un addebito circa la non veridicità e la falsità dei dati trasmessi da *Parte_1* attraverso il sistema WMF.

In tale contesto , comunque , una asserita falsità non può ritenersi provata , venendo meno il fondamento della prova della falsità dei dati dichiarati da *Parte_1* desumibile in modo decisivo dai dati della relazione investigativa confermati dal teste *CP_7* , atteso che gli altri testi (cfr. in particolare il teste *Tes_8*) hanno solo riferito in ordine alle modalità operative di “ tecnico on fiel “ oltre a confermare che i doc. 4 bis e 4 bis A , 6 bis e 6 bis A , 9 e 6 ter erano estratti dal sistema informatico WFM di *CP_1* .

In tale complessivo contesto infine non può attribuirsi , contrariamente a quanto pare assumere parte resistente a pagina 59 della memoria di costituzione in grado di rinvio, valenza probatoria decisiva al generico e massivo inciso contenuto nel verbale (non sottoscritto peraltro dal lavoratore) di audizione di *Parte_1* nel corso del procedimento disciplinare laddove si precisa (doc. 17 fasc. primo grado *CP_1*) : “ il sig. *Parte_1* ammette che i tempi di gestione delle WR non sono stati coerenti con quanto dalla stesso dichiarato nei sistemi . Il lavoratore specifica che le attività dichiarate sono state effettivamente svolte , solo le tempistiche sono

state talvolta allungate . Tale ammissione diventa a tutti gli effetti , secondo il collega , una proposizione di scuse per l'utilizzo distorto del tempo lavorativo “.

Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.

Ritenuta per quanto sopra , alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza dui rinvio, l'insussistenza dei fatti contestati , in applicazione della tutela prevista dal comma 4 dell'art. 18 l. 300/1970, va dichiarata la illegittimità dell'impugnato licenziamento ed in conseguenza *Controparte_1* va condannata, ex art. 18 comma 4 l.300/1970 , a reintegrare *Parte_1* nel posto di lavoro e al pagamento in favore dello stesso di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto , al tallone mensile di euro 2350,73 , dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione ed , in ogni caso ,non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del licenziamento al saldo ; *Controparte_1* [...] va altresì condannata al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

In ordine poi alla eccezione di aliunde perceptum proposta da parte resistente, il Collegio rileva il difetto di compiute allegazioni .

In proposito, la Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito “ l'onere, del datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'aliunde perceptum o percipiendi, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda (Cass. n. 22679 del 2018; n. 9616 del 2015; n. 23226 del 2010). (così in motivazione Cass. Ord. 10122/2022) “.

In punto di spese , la Corte di Cassazione ha chiarito che costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio di merito se riforma la sentenza di primo grado, ovvero sulle spese delle sole fasi d'impugnazione se rigetta l'appello ; che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato

all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (cfr. per l'affermazione di tali principi Cass.21626/2020; Cass.15506/2018 ; Cass. 20289/2015)

Tenuto conto di tali principi le spese processuali seguono la soccombenza di *Controparte_1* per tutti i gradi del giudizio e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'espletamento di attività istruttoria in primo grado , ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/ 2022 , nella misura specificata in dispositivo (euro 4000,00 per il primo grado; euro 3500,00 per il grado di appello ; euro 3000,00 per il grado di legittimità ; euro 3500,00 per il grado di rinvio : complessivamente euro 14000,00) ; con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

PQM

Decidendo in sede di rinvio, dichiara la illegittimità dell'impugnato licenziamento ed in conseguenza condanna *Controparte_1* , ex art. 18 , comma 4 l.300/1970 , a reintegrare *Parte_1* nel posto di lavoro e al pagamento in favore dello stesso di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto , al tallone mensile di euro 2350,73 , dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione ed , in ogni caso, non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del licenziamento al saldo ; condanna *Controparte_1* al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

Condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio liquidate in complessivi euro 14.000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge ; con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Milano 27 Giugno 2024

Il Presidente

Giovanni Picciau